

1500797-52.2021.8.26.0587

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... de que seria indiciado pela prática de Tráfico de Drogas. Ao Ministério Público respondeu: já possui passagem por tráfico de drogas. À Defensora respondeu: atribui a sua prisão pelo fato de estar se relacionando com a ex-namorada do policial militar Ewerton; tal policial já lhe conhecia e o conduziu à Delegacia da outra vez que foi preso; o policial Diogo estava no interior ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500943-64.2019.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500797-52.2021.8.26.0587 - Controle nº 2021/001624

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY FELIPE GONÇALVES DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia juntada às fls. 73/75, no dia 20 de outubro de 2021, por volta das 17h, na rua Manoel Neto, Barra do Sahy, nesta cidade e Comarca de São Sebastião, WESLEY FELIPE GONÇALVES DA SILVA, qualificado as fls. 04/05 e RENAN DE JESUS SILVA, qualificado às fls. 07/08, previamente ajustados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, traziam consigo, para fins de tráfico, 98 (noventa e oito) supositórios de cocaína, com peso aproximado de 85,12g (oitenta e cinco gramas e doze centigramas); 85 (oitenta e cinco) pedras de "crack", com peso aproximado de 24,98g (vinte e quatro gramas e noventa e oito centigramas), além de 18 (dezoito) porções de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha, pesando 55,27g (cinquenta e cinco gramas e vinte e sete centigramas), drogas que causam dependência química e psíquica, além da importância de R\$ 215,00 (duzentos e quinze reais) em notas diversas, sem autorização e em descordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, auto de constatação de fls. 15/16 e laudo pericial requisitado as fls. 17.

Em razão destes fatos, WESLEY FELIPE GONÇALVES DA SILVA, qualificado as fls. 04/05 e RENAN DE JESUS SILVA, qualificado as fls. 07/08, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incursos no artigo 33, caput, da Lei

nº 11.343/06, c/c artigo 29 do Código Penal.

Preso em flagrante delito, com fundamento nos artigos 310, II e 312, do Código de Processo Penal, a prisão em flagrante de Wesley foi convertida em prisão preventiva e foi concedida liberdade provisória a Renan, com aplicação de medida cautelar (fls. 53/56).

A denúncia foi recebida (fls. 83/84) e o réu Wesley Felipe Gonçalves da Silva foi citado (fls. 93) e apresentou resposta à acusação (fls. 114/116). Mantido o recebimento da denúncia, em instrução foi procedido ao interrogatório do réu e colhido o depoimento de 02 testemunhas (fls. 178/180).

Em relação ao réu Renan de Jesus Silva, preenchidos os requisitos legais, foi suspenso, em razão do disposto no artigo 366 do Código Processo Penal, o processo e o prazo prescricional (fls. 148/152).

Em debates de alegação finais, o Ministério Público, ao final da instrução probatória, requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, aduzindo que restaram provados os fatos narrados na peça acusatória, ao passo que a Defesa, aduzindo que não restou devidamente provado os fatos narrados e exordial acusatória, pugnou pela improcedência da pretensão punitiva estatal, em conformidade com o art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, na hipótese de condenação, no que tange a dosimetria, postulou a fixação da pena no mínimo legal, a compensação da atenuante da confissão informal com a agravante da reincidência. Quanto ao regime, pugnou pela sua fixação de acordo com a quantidade de pena a ser aplicada. Por fim, pugnou que o réu seja isento do pagamento de eventual multa a ser aplicada.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, o pedido formulado na presente ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva do crime está estampada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01, no boletim de ocorrência de fls. 10/12, auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, auto de constatação preliminar de fls. 15/16 e laudo toxicológico definitivo de fls. 108/110, bem como pela prova oral colhida.

A autoria é igualmente certa e repousa sobre a pessoa do réu.

Senão vejamos:

Na fase inquisitiva, o réu WESLEY FELIPE GONÇALVES DA SILVA preferiu manter-se calado (fls. 04/05).

O acusado WESLEY, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou os fatos. Disse que foi abordado pelos policiais no início daquela via, no momento em que saía do supermercado. Indagado pelos milicianos acerca de passagens criminais, o réu respondeu positivamente e, por isso, foi conduzido até a viatura policial e, em seguida, os policiais o levaram ao final daquela rua. Ficou no interior da viatura aguardando os policiais e pouco tempo depois eles trouxeram um segundo indivíduo e ambos foram levados à Delegacia de Polícia. Em um primeiro momento lhe disseram que se tratava de uma averiguação, mas depois lhe deram a notícia de que seria indiciado pela prática de Tráfico de Drogas. Ao Ministério Público respondeu: já possui passagem por tráfico de drogas. À Defensora respondeu: atribui a sua prisão pelo fato de estar se relacionando com a ex-namorada do policial militar Ewerton; tal policial já lhe conhecia e o conduziu à Delegacia da outra vez que foi preso; o policial Diogo estava no interior da viatura.

O policial militar Ewerton Heleno Candido de Oliveira, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que se encontrava em patrulhamento de rotina com seu colega de farda, pela Vila Sahy. Assim que adentraram à Rua Manoel Neto, local conhecido pela comunidade e pelo meio policial como área de tráfico de drogas, avistaram 03 indivíduos, sendo que um deles, ao visualizar a viatura, saiu em disparada. Da mesma forma, os outros 02 indivíduos também tentaram se evadir do local, mas sem sucesso. Realizada a busca pessoal em Wesley Felipe Gonçalves da Silva, vulgo "Tarzan", localizaram 24 pedras de crack, 08 eppendorfs de cocaína, 02 envólucros de maconha e R\$ 40,00 reais. Com Renan, localizaram 90 eppendorfs de cocaína, 61 pedras de crack, 16 envólucros de maconha e R\$ 175,00 reais. O depoente salientou que os acusados confessaram informalmente que estavam no local

para realizar tráfico de drogas e que já realizavam tal atividade há algum tempo, bem como que são moradores da Boraceia, no município de Bertioga.

No mesmo sentido foram os relatos do policial militar Diogo do Rosário Xavier, em nada divergindo o depoimento de ambos. À Defensora respondeu: haviam somente três pessoas no local, sendo que um indivíduo evadiu-se; não presenciou o réu comercializando drogas; não se recorda do réu de outras abordagens.

Pois bem.

As declarações do corréu Wesley não demonstraram harmonia com a dinâmica dos fatos comprovados nos autos. O réu negou os fatos que constam da denúncia. Disse que foi abordado pelos policiais no momento em que saía do supermercado, local em que foi comprar cigarros, o que não comprovou, seja por meio da nota-fiscal ou por meio de testemunhas. Aliás, no auto de exibição em apreensão de fls. 13/14 não consta a apreensão de maço de cigarros. Atribui a sua prisão pelo fato de estar se relacionando com a ex-namorada do policial militar Ewerton. Mais uma vez o réu não comprovou sua alegação, já que poderia ter arrolado a sua namorada, a fim de que esta confirmasse tal versão. Por oportuno, estranha-se o fato de que sua Defesa não indagou o referido policial acerca disso, a meu ver, deveras relevante. A versão dada por ele, portanto, é dissonante do que fora apurado durante a instrução criminal. Além disso, perante a autoridade policial nada disse acerca da suposta perseguição que estava sofrendo por parte do policial militar Ewerton. Tampouco, utilizou-se dos meios disponíveis para denunciar o policial, ainda que de forma anônima. Além disso, o réu também poderia ter registrado um boletim de ocorrência delatando o ilícito, supostamente cometido pelo mesmo policial, mas não o fez. Nenhuma comunicação à Corregedoria da Polícia Militar foi apresentada pela Defensoria Pública relatando a suposta perseguição.

A doutrina majoritária entende que:

"Cabe provar a quem tem interesse em afirmar. A quem apresenta uma pretensão cumpre provar os fatos constitutivos; a quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas. A prova da alegação (onus probandi) incumbe a quem a fizer (CPP, artigo 156, caput). Exemplo: cabe ao Ministério Público provar a existência do fato criminoso, da sua realização pelo acusado e também a prova dos elementos subjetivos do crime (dolo ou culpa); em contrapartida, cabe ao acusado provar as causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como circunstâncias atenuantes da pena ou concessão de benefícios legais". GN

Ademais, o acusado também não comprovou atividade lícita. As declarações produzidas nos autos, portanto, não têm o condão de alterar a situação fática, tampouco desacreditar os depoimentos dos agentes da lei.

Por outro lado, os policiais militares narraram os fatos em conformidade com as provas dos autos. Os policiais militares forneceram relatos uníssomos e claros, referindo que estavam em patrulhamento em local conhecido pela mercancia de entorpecentes e avistaram três indivíduos. Estes indivíduos empreenderam fuga ao avistarem os polícias e após breve perseguição, os agente da lei conseguiram deter os dois acusados. Realizada a busca pessoal, com Wesley, vulgo "Tarzan", localizaram 24 pedras de crack, 08 eppendorfs de cocaína, 02 envólucros de maconha e R\$ 40,00 reais. Os policiais confirmaram que o acusado confessou informalmente que estava no local realizando o tráfico de drogas.

Ademais, nada há que pudesse, ainda que superficialmente, colocar em dúvida a lisura do trabalho policial, pelo que o decreto condenatório é solução inevitável. Oportuno destacar que os relatos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Supremo Tribunal Federal (HC 87.662-PE,

Rel. Min. CARLOS BRITO, j.5.9.06) e no Superior Tribunal de Justiça (REsp. 151.150-SC, Rel. Min. JOSÉ DANTAS, j. 7.4.98).

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVA - SUFICIÊNCIA - Materialidade e autoria comprovadas - Réu preso em flagrante - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecente TESTEMUNHO POLICIAL - VALIDADE - O testemunho dos policiais tem validade como qualquer outro - Depoimentos coerentes - DESCLASSIFICAÇÃO - USO PRÓPRIO - INVIABILIDADE - A quantidade da droga apreendida, sua forma de acondicionamento e as circunstâncias em que se deu a prisão são fatores que, associados à prova produzida, levam à certeza de que o réu efetivamente se dedicava à mercancia de entorpecentes - PENA - MULTA - QUANTUM - INCONSTITUCIONALIDADE - INOCORRÊNCIA - O preceito secundário do crime de tráfico ilícito de drogas não fere os princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena - A quantidade da pena de multa cominada ao tipo penal em questão guarda relação com sua gravidade - Opção de política criminal adotada pelo legislador no combate ao tráfico ilegal de entorpecentes - Julgador que, no momento do cálculo da pena, deverá observar as especificidades do caso concreto - Condenação mantida- RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO" (TJSPap.n. 0084921-43.2010.8.26.0000 - 15ª Cam. Direito Criminal Rel. AMADO DE FARIA j. 16.12.2010) - gn.

Além disso, a quantidade e natureza das drogas apreendidas, a forma de acondicionamento, individualizadas e prontas para comercialização, a importância apreendida em notas diversas, as contradições e a inércia do réu no sentido de provar suas alegações (onus probandi - CPP, artigo 156, caput), a informal confissão, evidenciam que as drogas eram destinadas ao consumo de terceiros, não havendo falar-se em insuficiência probatória. Oportuno observar que o réu é reincidente específico.

Saliento que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente, nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06: "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal:

"A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Destarte, o conjunto probatório é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo nem de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. Ademais, o réu informalmente confessou que as drogas eram destinadas a terceiros e que estava traficando no local.

Quanto ao requerimento da Defensoria, acerca da isenção da pena de multa, ressalto que a pena de multa é cumulativa à pena corporal e não alternativa, sendo impossível a isenção de o seu pagamento. Ademais, é pacífico o entendimento de que a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador, portanto, descabida a pretensão de afastamento da pena de multa. Diante de tais circunstâncias, não resta outro caminho a seguir que não a condenação do acusado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06. Resta, enfim, a fixação da pena, porquanto inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que isente o réu de sanção.

Na primeira fase, sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo em fls. 90/92 que o réu não ostenta Maus antecedentes. Entendo não ser o caso de aumento da pena em razão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, na medida em que a situação do caso concreto, a meu ver, não desborda do que é esperado ordinariamente nos crimes

de tráfico de entorpecentes. Com Wesley foram apreendidos 24 pedras de "crack", 08 eppendorfs de "cocaína" e 02 envólucros de "maconha", o que de fato não desborda do que é esperado ordinariamente nos crimes de tráfico de entorpecentes. Assim, fixo a pena base no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, observo que o réu é reincidente específico (fls. 80/81). Observo, ainda, que está presente a atenuante da confissão (extrajudicial). Assim, no concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, compenso-as entre si, mantendo a pena no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo o réu reincidente específico, não faz jus ao benefício. Mantida, portanto, a pena fixada na fase anterior, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O regime inicial será o fechado, sendo o adequado ao cumprimento de pena, diante da reincidência específica e da quantidade de pena aplicada, na forma do artigo 33, § 2º, b, do Código Penal, uma vez que reincidente o réu. Nesse sentido: O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em razão da aferição negativa de circunstância judicial, que justificou o aumento da pena-base, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. STJ, HC 444200/RJ, Quinta Turma, rel.Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018.

Não é caso de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pois ausentes seus requisitos, considerando a quantidade de pena aplicada e a reincidência (Art. 44, I e II, CP). Pelo mesmo motivo, sobretudo pela quantidade de pena aplicada, não há que se falar em suspensão condicional da pena (Art. 77, CP). Inexistindo informações sobre o elemento subjetivo necessário à progressão de regime, bem como considerando a quantidade de pena aplicada e o tempo de prisão provisória cumprida pelo acusado, não há detração a ser procedida no momento, para fins de determinação de regime inicial mais brando, nos termos da Lei 12.736/2012. Para tanto, remeto à VEC a aplicação do art. 387, §2º, CPP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO o acusado WESLEY FELIPE GONÇALVES DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em seu valor unitário mínimo legal, no regime inicial fechado, por infringência ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c/c artigo 29 do Código Penal.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu. Oportunamente, intime-se para pagamento das multas.

Denego ao acusado o direito de apelar em liberdade. Ele permaneceu preso durante a instrução em razão de prisão em flagrante convertida em preventiva, pois concorrentes os motivos ensejadores da prisão preventiva. De fato, o delito de tráfico possui grande perniciosidade social, o qual está sempre associado a uma organização criminosa, em maior ou menor grau de proximidade, e com desdobramentos em outros crimes. Assim, a custódia cautelar do réu é necessária para a garantia da ordem pública. Aliás, se antes do julgamento de mérito que considerou o acusado culpado estava cautelarmente recolhido, com mais lógica assim deve permanecer após a condenação – TJSP, MS 113.332-3, Rel. Reynaldo Ayrosa. Ademais, há risco concreto de reiteração delitiva, considerando a reincidência específica. Recomende-se o acusado na prisão onde está recolhido.

Expeça-se guia de recolhimento provisória caso haja recurso interposto por qualquer das partes, encaminhando-a ao Juízo das Execuções Criminais competente e recomende-se o acusado na prisão onde está recolhido.

Oficie-se à Delegacia autorizando a destruição das drogas apreendidas.

O réu não apresentou prova da origem lícita do dinheiro com ele apreendido, razão pela qual decreto a sua perda e determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Expeça-se o necessário.

Condeno o réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei

1.060/50.

Sem prejuízo da expedição do necessário para intimação pessoal do réu, expeça-se o necessário quanto à destinação dos valores e drogas apreendidos.

Transitada em julgado a presente decisão, realizem-se as comunicações de praxe.

P. I. C.

Sao Sebastiao, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA